

1501043-60.2021.8.26.0583

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... da denúncia, com afastamento do tráfico privilegiado, porquanto faziam do tráfico seu meio de vida, e fixação do regime fechado. A defesa da ré MICKAELE pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de droga para uso pessoal, ou para uso compartilhado, ou, ainda, para o tráfico privilegiado, a absolvição no tocante ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

2ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, nº 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501043-60.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501043-60.2021.8.26.0583

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2335025/2021 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 21857843 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 1431/2021 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2335025 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 1431/21/210 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MICKAELE REGINA BURITÍ DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA ESSER DE SOUZA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra MICKAELE REGINA BURITÍ DA SILVA, brasileira, convivente, diarista (trabalha na roça), RG nº 57141180/SP, nascida aos 05/01/2000, natural de Presidente Prudente/SP, filha de Marinês de Souza Burití e de Cristiano Lourenço da Silva, residente na Rua Fortunado Baraldo, nº 92, Bairro Santa Rosa, Pirapozinho/SP; e, JUNIOR LOPES PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, convivente, servente de pedreiro, RG nº 62005921/SP, nascido aos 31/05/2003, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Creide de Lourdes Lopes e de Valmir Pereira dos Santos, residente na Rua Fortunato Baraldo, nº 92, Bairro Santa Rosa, Pirapozinho/SP, atualmente preso no CDP Caiuá, como incursos nos tipos penais dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº

11.343/2006, pela prática, em tese, dos seguintes fatos:

Consta, dos inclusos autos que, em data, horário e local incertos, mas certo que antes do dia 09 de dezembro de 2021, JUNIOR LOPES PEREIRA DOS SANTOS, qualificado às fls. 08 e MICKAELE REGINA BURITI DA SILVA, qualificada às fls. 07, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. Consta, ainda, que no dia 09 de dezembro de 2021, por volta de 06h30, na Rua Fortunato Baraldo, nº 92, Vila Santa Rosa, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, JUNIOR LOPES PEREIRA DOS SANTOS, qualificado às fls. 08 e MICKAELE REGINA BURITI DA SILVA, qualificada às fls. 07, guardavam e tinham em depósito, 3g de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 16) e auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 17).

Conforme o apurado, os denunciados são companheiros e associaram-se para o cometimento do crime de tráfico de drogas. Para a prática do comércio de drogas, os denunciados guardavam e tinham em depósito na residência uma porção de maconha, com peso líquido de 3g.

Na data dos fatos, os policiais militares e civis dirigiram-se até à residência dos denunciados para o cumprimento do mandado de busca domiciliar expedido por este Juízo no feito nº 1501029-69.2021.8.26.0456, tendo em vista que, após denúncias anônimas relatando a prática do comércio de drogas pela denunciada, foi observado pelos policiais, durante campana, movimentação de usuários de drogas conhecidos nos meios policiais nas proximidades da residência.

Durante o cumprimento da diligência foi localizado dentro de um pote de vidro uma porção de maconha junto à quantia de R\$27,00 (vinte e sete reais).

Em revista pessoal, foi localizada com a denunciada a quantia de R\$29,00 (vinte e nove reais), escondida na alça do seu sutiã e, com o denunciado foi apreendida a quantia de R\$20,00 (vinte reais) guardada no bolso do seu short.

Ao serem indagados sobre os fatos, os denunciados informalmente apresentaram versões contraditórias acerca da propriedade da droga. No entanto, o tio da denunciada e vizinho dos denunciados, confirmou a prática do crime de tráfico de drogas pelo casal.

Assim, as circunstâncias em que se deram os fatos, notadamente as informações da ocorrência do crime de tráfico de drogas na residência; a apreensão de droga no local; a quantia em dinheiro localizada, de origem lícita não comprovada, bem como o depoimento do tio da denunciada, não leva a ideação outra senão a de que os Denunciados estavam associados e que as drogas encontradas destinavam-se efetivamente ao consumo de terceiros, isto é, ao tráfico de drogas.

Os réus foram presos em flagrante delito e em audiência de custódia realizada no dia 10/12/2021, foi convertida a prisão de JUNIOR em preventiva, enquanto à ré MICKAELE foi concedida liberdade provisória cumulada com medidas cautelares (fls. 75/81).

A denúncia foi oferecida em 13/12/2021 (fls. 100/103) e em 15/12/2021 foi determinada a notificação dos réus (fl. 105).

Notificados, os acusados apresentaram defesas prévias às fls. 136/141 e 142/152, por meio de advogados constituídos.

Em 14/01/2022 foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 162/165).

Na solenidade realizada em 04/03/2022 foram ouvidas as testemunhas comuns Alexandre de Oliveira, Roberley Savalio da Silva, Ivan Alexandre da Silva Junior, Fabrício Gonçalves de Lima e Edna Nascimento de Oliveira Mascena, tendo havido desistência da testemunha comum Fabiano Lourenço da Silva e da testemunha de defesa Laurinda de Abreu Castelli Brianio Pereira. Na sequência, foram os réus interrogados. Em alegações orais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia, com afastamento do tráfico privilegiado, porquanto faziam do tráfico seu meio de vida, e fixação do regime fechado. A defesa da ré MICKAELE pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de droga para uso pessoal, ou para uso compartilhado, ou, ainda, para o tráfico privilegiado, a absolvição no tocante ao crime de associação criminosa, e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. A defesa do acusado

JUNIOR, por sua vez, pleiteou a absolvição quanto ao crime de associação ao tráfico, por ausência de provas; quanto ao crime de tráfico de drogas, requereu a desclassificação para o delito de uso de droga ou, subsidiariamente, para o crime previsto no artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006, ou tráfico privilegiado (fls. 226/227).

Às fls. 228/241 sobreveio laudo de exame pericial em aparelho celular da ré MICKAELE.

Manifestação das partes às fls. 258/259 e 263.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, examino diretamente o mérito.

A materialidade do fato restou devidamente comprovada nos autos pela reunião dos elementos sensíveis do crime, em especial o Auto de Prisão em Flagrante; os Autos de Exibição/Apreensão (fls. 16 e 53); o Auto de Constatação Preliminar (fl. 17); o Laudo Pericial Definitivo de Substância Entorpecente (fls. 122/124); e, os Laudos de Exame Pericial em Aparelhos Celulares (fls. 176/185 e 228/241).

Quanto à autoria, passo a uma análise pormenorizada do conjunto probatório.

Ao prestar depoimento em Juízo, o Policial Militar Ivan Alexandre da Silva Junior relatou que participou dando cumprimento a mandado de busca, a pedido da Polícia Civil. No dia dos fatos os alvos eram Fabiano, que morava em outra residência no mesmo terreno, e Mickaele. Contou que localizaram Fabiano em uma das residências, e na outra residência Mickaele estava na companhia do acusado Junior. Abordados, em revista pessoal encontraram com Mickaele a quantia de R\$ 29,00 em seu sutiã, e com Junior a quantia de R\$ 20,00 no bolso da bermuda, tendo Junior confirmado que estava morando com Mickaele. Segundo o policial, ao serem indagados, eles informaram que em um recipiente na estante havia uma quantidade de drogas e, ouvidos separadamente, cada um assumiu para si a propriedade da droga (03g de maconha), com versões contraditórias. Contou que havia informação de que os réus, e também Fabiano, traficavam, e havia notícias de que naquele endereço se reuniam pessoas que tinham envolvimento com drogas. Também disse que alguns meses antes Junior havia sido preso por tráfico de drogas. Informou que não foram encontrados objetos que indicavam o tráfico de drogas na residência, porém, receberam informação da vizinha Edna no sentido de que já havia flagrado Junior por algumas vezes, tendo ela relatado que Junior por diversas vezes foi flagrado no terreno ao lado do local, terreno esse de propriedade dela, alegando que Junior pulava o muro da residência dele para ter acesso a esse terreno, onde escondia droga, e embora o tivesse interpelado, ele continuava acessando o terreno para esconder drogas, todavia, não conseguiram comprovar essa informação.

De igual modo, o Policial Militar Fabrício Gonçalves de Lima narrou que os alvos da operação eram Fabiano e Mickaele, mas Junior se encontrava em uma das casas do quintal junto com Mickaele, que dizia ser sua amásia. Explicou que o entorpecente foi encontrado na casa dos fundos, onde estavam os acusados, e os dois, ouvidos separadamente, assumiram a propriedade da droga e disseram que era para uso próprio. Além da droga, foram apreendidos R\$ 29,00 com Mickaele, vinte e poucos reais com Junior, e mais uma pequena quantia de dinheiro no recipiente onde estava a droga, tendo os dois alegado serem usuários de drogas, mas já era de conhecimento da polícia que ambos fazem uso e também praticam a venda de entorpecentes. Disse que Fabiano era o alvo da operação, porém com ele não foi encontrado nada, ele não comentou nada sobre os dois venderem droga. Informou ter conversado com a vizinha de nome Edna e ela contou fatos que acontecem no terreno do lado, no sentido de ela já ter visto o acusado algumas vezes lá, pois ele pulava o muro, enterrava entorpecente no local, mexia com droga dentro do terreno, inclusive ela disse que já havia pedido várias vezes para ele parar de fazer aquilo, porque ela era proprietária e se pegassem a droga poderiam achar que ela tinha algum envolvimento. Por fim, aduziu que na residência não foram encontrados elementos indicativos de tráfico de drogas, como balança, anotações.

O Policial Civil Alexandre de Oliveira, por seu turno, relatou que também participou da busca na residência, cujo alvo era o tio de Mickaele, não sabendo

dizer se os acusados eram investigados, pois apenas foi prestar apoio na busca. Contou que na residência foram encontrados 3g de maconha e dinheiro, e que cada um dos acusados deu versões contraditórias, pois ouvidos separadamente, ambos assumiram a propriedade da droga como sendo deles, cada um disse que era deles, não sabem de quem realmente era. Disse que segundo relatos de outros policiais que estavam no local, a residência já foi alvo de outras buscas. Narrou ter acompanhado buscas no terreno ao lado, mas não encontrou drogas, e em conversa com Fabiano, este disse que já mexeu com drogas, mas não mexia mais, porque estava doente, e não se recorda de ele ter falado algo sobre Junior e Mickaele.

O Policial Civil Roberley Savalio da Silva, por sua vez, narrou que os alvos da busca eram Mickaele e Fabiano, e que chegando lá encontraram a ré, o acusado Junior, e Fabiano, tio dela. Nas buscas encontraram 3g de maconha no interior do imóvel, 27 reais escondidos dentro do sutiã de Mickaele. Eles foram indagados se havia telefones celulares, tendo eles, a princípio, negado, mas encontraram dois aparelhos, e posteriormente Mickaele e Junior assumiram que os aparelhos eram deles. Quanto ao entorpecente, eles divergiram quanto à propriedade, pois Mickaele dizia que era dela, enquanto Junior dizia que era dele, eles foram ouvidos separadamente. Disse que policiais da cidade que participavam da operação disseram que ali é um ponto de tráfico de drogas. Também informou que o dinheiro que foi apreendido era um pote com várias moedas, e pela experiência que possuem é bastante parecido com o movimento de tráfico de entorpecentes.

A testemunha Edna Nascimento de Oliveira, mencionada pelos policiais, também foi ouvida em Juízo, ocasião em que declarou que sua mãe possui um terreno vizinho à casa dos acusados, e que eles moram na esquina e sua residência é ao lado da casa vizinha deles. Alegou que como passa a maior parte do tempo trabalhando, nunca presenciou movimentação de tráfico de drogas na residência dos réus, nem tampouco sabe dizer se eles já tiveram envolvimento com tráfico de drogas, negando, ainda, ter informado aos policiais ter visto movimentação de tráfico na casa dos acusados, nem tampouco ter visto Junior pulando para dentro do terreno, afirmando que apenas cuida do terreno para não deixar acumular mato e que nunca encontrou drogas ali. Entretanto, ao ser advertida sobre as consequências advindas em caso de falseamento da verdade e indagada se os policiais haviam mentido em Juízo, Edna alterou a versão apresentada, afirmando que, na verdade, foi sua companheira quem conversou com os policiais tendo ela concedido a eles liberdade para adentrarem o terreno, e acrescentou que comentou com os policiais que já pediu a Junior que não entrasse mais no terreno, pois ele entrava para fazer uso da droga dele.

Os réus negaram a prática dos crimes.

JUNIOR LOPES PEREIRA DOS SANTOS alegou em Juízo que é usuário de maconha há uns 05 meses, e que a maconha encontrada na residência pertencia a Mickaele, para uso dela, e o dinheiro era de sua propriedade, e negou ter dito aos policiais que a maconha lhe pertencia. Aduziu que o dinheiro era oriundo de seu trabalho e que o deu para Mickaele guardar, e ela, por sua vez, tem costume de guardar dinheiro dentro do sutiã.

Ao ser questionado sobre a fotografia constante no laudo pericial de seu aparelho celular, especificamente à fl. 179, que retrata grande quantia de dinheiro, confirmou que esse dinheiro lhe pertencia, que o juntou com seu trabalho e o sacou do banco para comprar mantimentos para a residência.

Aduziu que Fabiano é tio de Mickaele, mas não tem amizade com ele; que já chegou a usar droga junto com Mickaele e que a droga apreendida era para uso de ambos.

MICKAELE REGINA BURITÍ DA SILVA, por sua vez, alegou que é usuária de maconha há uns 6 anos ou mais, e que na data dos fatos os policiais encontraram 3g de maconha, que havia acabado de comprar para usarem uma vez por semana, durante meses, pois faz uso da droga junto com Junior. Informou ter comprado a droga em Presidente Prudente/SP por R\$ 10,00, e que havia comprado um dia antes, no período noturno. Contou, ainda, que quando conheceu Junior ele já era usuário de maconha. Com relação ao dinheiro apreendido, disse que era de Junior, ele pediu que guardasse, esclarecendo que ele trabalhava na Umoe, mas deu quebra de contrato, e por isso ele estava recebendo dinheiro, sendo que no dia dos fatos ele havia recebido R\$ 50,00. Sobre a fotografia constante no aparelho celular de Junior, de grande quantia em

dinheiro (fl. 179), disse ter conhecimento dessa fotografia, aduzindo que tirou foto do "acerto" dele com a Umoe, que era de R\$ 1.700,00 a R\$ 2.000,00, e que ao ser indagada sobre o que fizeram com esse dinheiro, disse que os policiais o levaram. Aduziu que fumavam no máximo uma ou duas vezes na semana. Contou que como Fabiano é usuário de drogas, ele tira muitas coisas de sua casa para vender, então acabam se desentendendo, e que ele disse aos policiais que a interroganda e Junior vendem drogas porque os policiais disseram que se ele não dissesse nada, ele não iria sair de lá (da Delegacia de Polícia).

As versões apresentadas pelos acusados em seus interrogatórios estão repletas de contradições, não merecendo credibilidade.

A uma, Junior disse que é usuário de maconha há 05 meses, enquanto Mickaele disse que convive com ele há cerca de cinco anos e que quando o conheceu ele já fazia uso da droga. A duas, quanto ao dinheiro apreendido no processo, Michaelle disse que era proveniente da rescisão de contrato de trabalho de Junior junto à Umoe Bioenergy, enquanto Junior disse que era proveniente de seu trabalho como servente de pedreiro. A três, o acusado tirou foto de uma grande quantia em dinheiro - mais de R\$ 3.000,00, composta de notas de R\$ 100,00 e de R\$ 50,00 (fl. 179) - e os réus não souberam explicar a origem do dinheiro, tendo Mickaele dito que era oriundo do "acerto" de Junior com a Umoe Bioenergy, porquanto ele recebeu entre R\$ 1.700,00 a R\$ 2.000,00 (embora na fotografia, claramente, há mais de R\$ 3.000,00), ao passo que Junior disse que havia juntado esse dinheiro com seu trabalho e que o havia sacado para a compra de mantimentos para a residência; ademais, Mickaele relatou que esse dinheiro foi levado pelos policiais, o que, evidentemente, não é verdade, haja vista que a quantia apreendida no feito é de apenas R\$ 76,00 (setenta e seis reais) (fl. 53).

Aliadas a todas essas contradições apresentadas pelos réus, tem-se as contradições apresentadas pela testemunha Edna Nascimento de Oliveira em seu próprio depoimento, que demonstrou não querer falar a verdade, porquanto, os quatro policiais ouvidos em Juízo disseram que, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Mickaele, Edna relatou a eles que Junior costuma usar o terreno de sua propriedade para esconder drogas, e que já havia pedido a ele que não fizesse mais aquilo, entretanto, em Juízo, mostrou-se receosa, intencionando negar essa informação, e após advertida sobre o dever legal de dizer a verdade, afirmou que, de fato, Junior já pulou para dentro do terreno, dizendo, todavia, que ele o fez para "usar a droga dele", diversamente do que alegara para os policiais em momento anterior.

Não se pode olvidar, ainda, que foi expedido mandado de busca e apreensão para as residências de Mickaele e Fabiano justamente em razão da existência de diversas denúncias anônimas de que, naquele endereço, havia comércio de drogas, o que restou confirmado pela apreensão de entorpecente e dinheiro em notas diversas (inclusive escondido dentro o sutiã), bem como pelas mídias constantes nos aparelhos celulares dos acusados.

A propósito, submetido o aparelho de Mickaele a exame pericial, foram verificadas trocas de mensagens com conteúdo atinente ao tráfico de entorpecentes e fotografia da acusada com elevada quantidade de dinheiro, conforme fls. 228/241. Observo que as alegações da defesa de pertencer o celular à Sra. Vanilda, avó da ré (fls. 258/259) não prosperam quanto ao laudo de fls. 228/241, referido nesta sentença. É inclusive oportuno destacar que o aparelho celular submetido à perícia objeto das fls. 228/241 possuía como conta de e-mail vinculada michaelereginaaag@hotmail.com, não deixando dúvidas de que se tratava do aparelho celular da acusada.

Por fim, para arrematar, ressalte-se o teor das declarações prestadas por Fabiano Lourenço da Silva em solo policial:

"É tio de MICKAELE; é usuário de entorpecente "crack"; no terreno em que reside há mais outras duas casas, sendo que MICKAELE e o amásio dela JUNIOR residem em uma delas; trabalhava na roça de batata, por isso não ficava muito em sua residência, mas há três semanas machucou-se e então tem permanecido no imóvel; que JUNIOR e MICKAELE têm realizado a mercância de entorpecentes ali no imóvel; que as pessoas vão até ao imóvel em carros, param em frente e então normalmente JUNIOR é quem vai até os automóveis realizar a entrega do entorpecente e receber pela venda, mas

MICKAELE também o faz; que eles vendem maconha e crack; por diversas vezes JUNIOR lhe vendeu crack, esclarecendo que JUNIOR separa uma pequena quantia (gesticulou com a mão indicando o tamanho) e lhe vende por R\$ 10,00 (dez reais). Que não tem participação com o tráfico de entorpecentes, apenas é usuário de crack; não sabe com quem JUNIOR e MICKAELE adquirem as substâncias; não sabe confirmar se eles têm escondido entorpecentes no terreno próximo a sua residência". (fl. 09)

Conquanto Fabiano não tenha sido ouvido em Juízo, seu depoimento prestado em fase inquisitorial está em consonância com o conjunto probatório, servindo como mais um elemento para a formação da convicção desta Magistrada.

Não restam dúvidas, portanto, de que os acusados, efetivamente, praticaram o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não havendo, por conseguinte, que se falar em desclassificação para o delito capitulado no artigo 28 da mesma lei, nem tampouco para a figura prevista no artigo 33, § 3º, também da Lei nº 11.343/2006, uma vez que as circunstâncias em que se deram os fatos, notadamente as denúncias de que no endereço dos denunciados havia tráfico de entorpecentes, apontando, inicialmente, Mickaele e seu tio como traficantes, a apreensão de droga no local, bem como as fotografias de vultuosas quantias em dinheiro com os réus levam à conclusão de que a droga apreendida destinava-se efetivamente ao tráfico. Ainda que os réus sejam, de fato, usuários de drogas – mesmo porque fotografias constantes nos aparelhos celulares demonstram, também, os réus fazendo uso de baseados de maconha –, a condição de usuário não ilide a de traficante; pelo contrário, é bastante comum que usuários pratiquem a mercancia de drogas para o sustento do próprio vício. A propósito:

Apelação – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso defensivo – Pedidos de absolvição por falta de provas e de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade – Prova oral harmônica e coesa – Apelante que trazia consigo droga perniciosa ("crack"), em quantidade elevada (17 porções) e acondicionadas em embalagens típicas de mercancia – Circunstâncias da prisão reforçam o "animus" de traficância – Policiais militares receberam notícia-crime anônima dando conta de que a apelante praticava a narcotraficância, o que foi confirmado pela prisão em flagrante – Versão da sentenciada dissociada das provas coligidas – Desnecessidade de que os agentes públicos presenciem o ato de mercancia – Crime de ação múltipla ou conteúdo variado – Bastante comum a figura do "traficante-usuário" ou "usuário-traficante", que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício – Penas bem dosadas e regime inicial fixado corretamente, em atenção aos parâmetros legais aplicáveis à espécie, não merecendo qualquer reparo – Recurso não provido. (TJ-SP - APR: 15002257320198260585 SP 1500225-73.2019.8.26.0585, Relator: Juscelino Batista, Data de Julgamento: 23/03/2021, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/03/2021)

Isto posto, vale salientar que os acusados não fazem jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Para que haja a incidência da benesse é necessário o preenchimento de quatro requisitos, cumulativos: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; e, (d) não integrar organização criminosa. In casu, embora os réus não ostentem condenação criminal, há provas concretas de que se dedicam a atividades criminosas, especialmente o crime de tráfico de drogas, haja vista que, em 15/09/2021 foram presos em flagrante delito também pelo delito de tráfico de entorpecentes, porque com eles, no mesmo endereço, foram apreendidos 16 papелotes de "cocaína", além de dois invólucros de maconha, destinadas ao fornecimento a terceiros, motivo pelo qual foram denunciados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes nos autos nº 1500789-87.2021.8.26.0583, em trâmite na 1ª Vara desta Comarca; e, apenas três meses depois, foram novamente presos com substâncias entorpecentes na residência, o que denota que fazem da mercancia de drogas seu meio de vida, de onde tiram seu sustento.

A propósito, vale ressaltar que, no citado processo, os acusados foram beneficiados

com a liberdade provisória com medidas cautelares em 16/09/2021.

Bem se sabe que aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida, não fazem jus ao benefício, dado que essa causa de redução da pena é destinada àquele que age por um impulso, em situação isolada no tráfico de drogas, incidindo na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, não sendo o caso destes autos. Nesse sentido:

"Tráfico de entorpecentes. (...) Insurgência defensiva em face da pena. Reprimendas irreprocháveis. Impossibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado. Benefício ao qual não fazem jus às acusadas. Dedicção à atividade criminosa. Volume considerável de droga que revela não serem as rés meras aventureiras no ramo da narcotraficância (...) Precedentes do STJ. Negado provimento ao apelo". (TJSP; Apelação Criminal 0002163-92.2017.8.26.0539; Relator: Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 01/02/2020)

De tudo o que foi exposto, tem-se que o acervo probatório é vasto e suficiente para ensejar a condenação dos réus pelo delito de tráfico de drogas, restando comprovada a autoria e a materialidade, assim como a tipicidade delitiva, posto que não se fazem presentes causas excludentes de ilicitude, ao mesmo tempo em que os réus eram plenamente imputáveis e lhes era exigido que agissem de forma diversa.

Por outro lado, no que toca ao crime de associação ao tráfico de drogas, é imperiosa a absolvição.

O mero concurso de pessoas (CP, art. 29) para a prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 não induz necessariamente à existência de uma associação para tanto. A configuração do delito do art. 35 da mesma Lei exige a união estável e permanente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Associação para o tráfico - Autoria e materialidade delitiva comprovadas apenas em relação ao delito inserto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas e regime prisional fixados com critério em relação a este delito - Associação para o tráfico não configurada - Absolvição que se faz necessária - Ausência de comprovação de que o apelante tenha efetivamente praticado quaisquer atos que indicassem a sua associação, de forma estável e permanente, para a prática da mercancia nefanda - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15017550720208260544 SP 1501755-07.2020.8.26.0544, Relator: Ricardo Sale Júnior, Data de Julgamento: 12/05/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2021)

Não há provas suficientes de que a união entre os acusados era estável e permanente.

Passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no art. 68 do Código Penal.

Quanto à ré MICKAELE, no que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a capacidade do autor de perceber os fatos e de se determinar de acordo com eles e a reprovação social que sua conduta merece, não há elementos suficientes a se valorar. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, a ré é primária. No que diz respeito à conduta social, "deve ser valorada pelo desempenho do réu na sociedade, na família e no trabalho, e não em relação aos fatos criminosos e atos infracionais supostamente cometidos, ou comprovadamente perpetrados, os quais devem ser apreciados, quando cabível, na avaliação dos antecedentes" (TJPR - 2ª C. Criminal - AC - 1360784-6 - Francisco Beltrão - Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime - J. 25.06.2015), não há elementos nos autos para valoração dessa circunstância. Na análise do vetor circunstâncias, previsto no art. 59 do Código Penal, deve ser apreciado o disposto no art. 42 da Lei de Drogas: Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do

agente. Na espécie, a natureza e a quantidade da droga não ensejam aumento da reprimenda mínima. Os motivos são inerentes ao próprio tipo violado, porquanto o agente, em tal conduta, visa o desejo de obtenção de lucro fácil. As consequências do ilícito são gravíssimas, em razão da má repercussão e da influência nefasta que esta modalidade delituosa exerce, especialmente, sobre os adolescentes, com resultados desastrosos nos núcleos familiares, com sua desestruturação e/ou muitas vezes, com sua destruição. A droga é causa de morte prematura de muitas pessoas em todo o mundo, de forma que tal espécie de crime merece pronto e eficaz combate da sociedade, mediante reprimenda exemplar para coibir sua prática. Entretanto, tais argumentos já foram considerados pelo legislador penal quando da elaboração do preceito secundário. Não há informações suficientes nos autos para valoração da personalidade do agente. Por fim, não que se há falar em comportamento da vítima, uma vez que se trata de crime vago. Assim sendo, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem aplicadas e, à míngua de causas de diminuição ou de aumento, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos, em virtude dos parcos recursos financeiros da acusada (art. 49, § 1º, do CP e 43 da Lei nº 11.343/2006).

Como é cediço, para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). Aliado a isso, o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

In casu, a ré permaneceu presa durante todo o processo, não havendo tempo de prisão a ser detraído.

Assim sendo, fixo o REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, "a", do Código Penal).

Ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e de conceder o "sursis".

Quanto ao réu JUNIOR, no que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a capacidade do autor de perceber os fatos e de se determinar de acordo com eles e a reprovação social que sua conduta merece, não há elementos suficientes a se valorar. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, o réu é primário. No que diz respeito à conduta social, "deve ser valorada pelo desempenho do réu na sociedade, na família e no trabalho, e não em relação aos fatos criminosos e atos infracionais supostamente cometidos, ou comprovadamente perpetrados, os quais devem ser apreciados, quando cabível, na avaliação dos antecedentes" (TJPR - 2ª C. Criminal - AC - 1360784-6 - Francisco Beltrão - Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime - J. 25.06.2015), não há elementos nos autos para valoração dessa circunstância. Na análise do vetor circunstâncias, previsto no art. 59 do Código Penal, deve ser apreciado o disposto no art. 42 da Lei de Drogas: Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, a natureza e a quantidade da droga não ensejam aumento da reprimenda mínima. Os motivos são inerentes ao próprio tipo violado, porquanto o agente, em tal conduta, visa o desejo de obtenção de lucro fácil. As consequências do ilícito são gravíssimas, em razão da má repercussão e da influência nefasta que esta modalidade delituosa exerce, especialmente, sobre os adolescentes, com resultados desastrosos nos núcleos familiares, com sua desestruturação e/ou muitas

vezes, com sua destruição. A droga é causa de morte prematura de muitas pessoas em todo o mundo, de forma que tal espécie de crime merece pronto e eficaz combate da sociedade, mediante reprimenda exemplar para coibir sua prática. Entretanto, tais argumentos já foram considerados pelo legislador penal quando da elaboração do preceito secundário. Não há informações suficientes nos autos para valoração da personalidade do agente. Por fim, não que se há falar em comportamento da vítima, uma vez que se trata de crime vago. Assim sendo, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem aplicadas. Noutro giro, verifica-se a presença da atenuante referente à menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP); entretanto, deixo de proceder à redução da pena, tendo em vista que nesta fase é vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do STJ. Desta feita, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pena esta que torno definitiva, à míngua de causas de aumento e de diminuição.

Fixo cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos, em virtude dos poucos recursos financeiros do acusado (art. 49, § 1º, do CP e 43 da Lei nº 11.343/2006).

Como é cediço, para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). Aliado a isso, o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

In casu, o réu está preso desde 09/12/2021, portanto, há pouco mais de três meses, tempo insuficiente para a alteração do regime.

Assim sendo, fixo o REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, "a", do Código Penal).

Ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e de conceder o "sursis".

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR os réus MICKAELE REGINA BURITÍ DA SILVA, RG nº 57141180/SP, CPF 471.579.468-31, nascida aos 05/01/2000, natural de Presidente Prudente/SP, filha de Marinês de Souza Burití e de Cristiano Lourenço da Silva; e, JUNIOR LOPES PEREIRA DOS SANTOS, RG nº 62005921/SP, nascido aos 31/05/2003, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Creide de Lourdes Lopes e de Valmir Pereira dos Santos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do mínimo legal vigente na data dos fatos, e ABSOLVÊ-LOS quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Quanto à ré MICKAELE, considerando que respondeu o processo todo em liberdade, sem que houvesse notícias do descumprimento das cautelares que lhe foram impostas, poderá permanecer em liberdade para recorrer, mantidas, entretanto, as medidas cautelares aplicadas na decisão de fls. 75/81, até o trânsito em julgado desta sentença.

Considerando que JUNIOR respondeu ao processo todo privado de sua liberdade, que fora fixado o regime semiaberto e que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da reiteração delitiva demonstrada, haja vista que beneficiado com a liberdade provisória em 16/09/2021, nos autos nº 1500789-87.2021.8.26.0583, veio a ser novamente preso por tráfico de drogas neste processo apenas três meses depois, denego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Não obstante, nos termos dos pronunciamentos recentes do C. Superior Tribunal de Justiça e para que não haja ofensa à homogeneidade, determino a adequação da prisão

provisória às condições do regime semiaberto ora imposto, com transferência do réu para estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto.

Quando da prisão dos réus, além das drogas, foram apreendidos três aparelhos celulares (fl. 17) e a importância de R\$ 76,00 em dinheiro (fl. 53).

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do FUNAD, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 647 da repercussão geral, por maioria, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE 638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17/05/2017).

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias.

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos e valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e, tendo em vista que os sentenciados não se desincumbiram do seu ônus, eis que não restou devidamente comprovado que o dinheiro apreendido fosse oriundo de trabalho lícito, decreto o perdimento dos aparelhos celulares pertencentes aos réus e da importância em dinheiro, a ser revertida ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

O aparelho celular de propriedade da Sra. Vanilda, avó de Mickaele, deverá ser a ela restituído.

Determino, ainda, a destruição das amostras da droga apreendida, bem mediante certificação nos autos (artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 525 das NSGJ).

Não há danos a serem reparados, motivo pelo qual deixo de fixar valor mínimo para indenização (art. 387, IV, CPP).

Condeno os réus, também, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Independentemente do trânsito em julgado, oficie-se à Secretaria de Administração Penitenciária para que, com a urgência que o caso requer, remova o réu JUNIOR para unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

Após o trânsito em julgado: a) expeçam-se mandados de prisão em regime semiaberto e guias de recolhimento; b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, com a devida identificação dos réus, acompanhada de fotocópia da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c 15, inciso III, da Constituição Federal; c) oficie-se o Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; d) proceda-se à liquidação das custas e da pena de multa e, a seguir, intímem-se os réus para pagamento, no prazo de 10 (dez) dias. Deverão ser os réus advertidos de que, exceto em caso de absoluta impossibilidade econômica, que deve ser devidamente comprovada, o não pagamento da pena de multa impede a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade, a teor do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na ADI 3.150/DF, e encampado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no REsp 1850903-SP, julgado em 28/04/2020 e divulgado no Informativo de Jurisprudência nº 671; e) oficie-se à SENAD, para fins do disposto no artigo 63, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e, f) intime-se a Sra. Vanilda, avó de Mickaele, para restituição do aparelho celular a ela pertencente.

Publique-se. Intímem-se. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Pirapozinho, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA